

洞秘密窃取的情况，其行为不构成犯罪。另一种观点认为，平台及系统并无实际处置财物的能力，设定系统规则的是平台背后的人及其单位，而平台及其系统不过是实现其背后的人及单位的处分的意思表示的辅助工具，而系统的预设规则的设立，不过是为了最大限度地按照自然人及单位的真实意思表示，提高交易效率的同时，以规则确保合同目的的实现，降低商业风险，而对平台规则漏洞的利用，本质绕开了自然人及单位的真实意思表示，以虚假的形式达成预设规则的假象，违背自然人及单位订立此类合同的真实意思表示，误将实质不符合的预设规则的合同订立且履行，而预设规则的达成系被告人利用平台系统设定漏洞，虚构交易的刷单行为所引起，而行为人造假达成预设规则目的意在非法占有钱款，故而应当以合同诈骗罪定罪。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定，有以其他方法骗取对方当事人财物的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的构成合同诈骗罪。行为人有无非法占有目的，在订立合同和履行合同的过程中，采用欺骗手段，致使合同相对方陷入错误认识而处分财物，且达到数额较大标准，是判断是否构成合同诈骗罪的要件。

具体到本案，首先，可以确定的是双方签订了相关的借款合同，且贷款公司系从事经营活动的市场主体，通过收取利息获得利润，此点其贷款账户的申请及其使用以及贷款发放、还款等行为均可以佐证，且系在双方订立、履行合同的过程中。

其次，被告人采取了欺骗的手段。其了解“订单贷”“极速收”产品的内容，尤其是评定规则系依据商家的外部客户订单金额为基数，按照对商家的历史信用、商户评级、经营状况等参数设置，知晓贷款的还款期限，并知道按时还款可以增加信用，提升销售额可以提升贷款金额。被告人虽辩称不了解上述相关内容，未主动申请系平台主动发放，贷款发放金额与店铺交易流水无直接因果关系等，但是通过其注册店铺及贷款账号的时间，还款的时间及次数，用自己控制的公司刷单提升在途营业额，虚假发货及利用优惠券支付少量实付款等均可以佐证其知晓贷款发放预设规则，而其所采取的上述欺骗手段目的就是达成系统预设的贷款发放规则。再次，判断其是否具有非法占有的目

的，也是本案合同诈骗罪认定的关键。原则上其采取了上述客观的欺骗行为即可以认定其具有非法的占有目的，且通过其上述行为，可以判断此种非法占有目的产生于欺骗行为之前，这点可以从其所控制的公司及其在京东的店铺并无多少真实的营业额，而其存续的时间段与其申请贷款的时间段相互吻合，在其贷款申请后相关店铺也无实际的营业，且在其贷款之前其本人存在多起民事纠纷，且个人已无任何偿还能力，其在得到大额贷款后无积极履行偿还的行为等推定。最后，贷款公司发放贷款额度与其欺骗行为之间具有直接因果关系。贷款公司之所以依据上述因素及其基数设定贷款发放额度，旨在待店铺的销售额实际入到期合作的结算方的支付钱包后可以划扣偿还贷款为担保，结合其还款信用评定，从而降低贷款不能回收的风险，而被告人采取的虚假手段致使上述合同目的直接落空，如贷款公司知晓上述欺骗行为定然不会发放贷款，从而造成财产损失。综上，被告人在合同成立和履行过程中采取了欺骗行为，且在其实施欺骗行为之初，获取贷款前就已产生非法占有目的，而后续亦未积极履行合同以及为合同的履行而作努力，其行为构成合同诈骗罪。

二、尹某犯罪金额认定

合同诈骗罪的责任要素除要求是故意外，还要求被告具有非法占有的目的。虽然被告人尹某采取欺骗手段获取了300余万元的贷款，但因小额贷款公司并非金融机构，无法认定骗取贷款罪，而如果认定合同诈骗罪的金额，尚需要考虑其非法占有目的，具体到本案中，被告人尹某虽然通过欺骗手段获取了贷款，且未按照贷款用途用于指定的店铺，擅自将相关款项挪作其在京东的其他店铺的进货和广告费的大额实际支出，其上述行为虽然不符合贷款约定用途，涉及以欺诈手段订立合同，即便合同不撤销，也存在合同违约行为，但是不能仅据此认定被告人无归还此部分贷款的意图，也无法评判后续其该类产品实销后是否确无履行此部分贷款偿还的能力，故依照有利于被告人的原则，法院对其明知自己已无偿还能力，仍然将贷款中的10万元无条件转赠让人用于挥霍，该10万元可以认定为其具有非法占有目的，认定为合同诈骗金额。

综上，在利用系统规则漏洞的案件审查时，不能仅以平台为机器，机器不

能被骗为由推翻诈骗犯罪的构成。在侵害财产类的犯罪中，机器仅仅是犯罪行为所作用的对象或借助的实现骗取行为的手段，真正的被害对象仍为机器背后的人或单位，正如本案中，尹某利用的是贷款系统漏洞或者规则，但是真正受害的是贷款公司，利用机器所实施的骗取机器背后财产所有权人的行为仍然构成诈骗类犯罪。对该类犯罪的审查，应该回到犯罪构成的实质要件的审查分析认定上去，而非仅纠结于犯罪手段的采取和利用。而在审查合同诈骗罪时，既要着重审查是否存在经济合同，是否有欺骗手段，财产交付与欺骗手段之间的因果关系等，也要着重审查是否具有非法占有的目的，要综合其履行能力、有无履行行为、有无挥霍行为、是否按照规定用途使用等方面综合认定，按照主客观相统一的原则认定其犯罪金额。

编写人：北京市海淀区人民法院 尹鹏展 王成凤

使用虚假证明文件擅自过户不动产归自己占有后 将不动产抵押借款的行为应如何定罪及处罚

—— 窦某某合同诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03刑终39号刑事裁定书

2. 案由：合同诈骗罪

【基本案情】

2017年2月至12月，窦某某在明知其母亲不同意将名下房产过户给自己的情况下，通过中介伪造其母亲已去世的事实并将其母亲名下房产过户至自己

名下，虚构其以合法方式取得上述房产且上述房产归自己所有的事实，以该房产为抵押与被害人倪某签订借款、抵押合同并办理抵押登记，骗取倪某钱款共计人民币260万元，后窦某某陆续归还人民币56.1万元，其余赃款损失，后窦某某逃匿。

【案件焦点】

使用虚假证明文件擅自过户不动产归自己占有后将不动产抵押借款的行为应如何定罪及处罚。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：被告人窦某某在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于窦某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。责令窦某某退赔被害人经济损失。北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决：

一、窦某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币11万元，剥夺政治权利二年；

二、责令窦某某退赔人民币2039000元，发还被害人倪某。

一审宣判后，被告人提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：一审法院根据窦某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于使用虚假证明文件擅自过户不动产归自己占有后将不动产抵押借款的行为应如何定罪及处罚，对此，阐述如下。

一、窦某某伪造其母亲已去世的事实擅自过户房产给自己占有的行为应认定为盗窃罪

1. 窦某某的前述行为不构成诈骗罪。该行为如要认定诈骗罪，要求不动产登记部门对涉案房产具有处分权，由此，窦某某才能借由不动产登记部门受到欺骗并作出处分，来非法占有其母亲的房产。鉴于不动产登记是当事人基于处不动产权益的私人行为，向不动产登记部门提出申请，由不动产登记部门进行形式审查后，对当事人意图实现不动产权益处置，通过公权力进行确认与宣告，这一过程不宜认为不动产登记部门对不动产具有处分权。另外，窦某某虚构的是其因母亲去世而继承房屋的事实，继承取得的物权登记属宣示登记，即登记本身不生物权变动，物权发生变动的原因是一定的法律事实或事件，只是在法律有规定时，登记成为不动产处分要件，①即在窦某某伪造母亲去世其继承房屋的行为完成时物权就已完成变动。因此，窦某某的相关行为不构成诈骗罪。

2. 在不不动产权利人不知情的情况下，擅自将他人名下的不动产转移给自己占有的行为可认定为盗窃罪。从犯罪对象来看，盗窃罪是侵害财产的犯罪，而不动产的财产价值集中体现在不动产产权上。不动产产权具有占有、使用、收益、处分的权能，亦有相应的财产性利益。财产性利益因具有可管理性、可转移性和价值性，其范围能够合理限定，可以成为盗窃罪

的对象，②因而不动产 产权因具有财产性利益，可以成为盗窃罪的对象。

从非法占有来看，占有指的是人对财物事实上的控制和支配，非法占有 包括排除权利者，将他人之物当成自己的所有物一样按照其用途进行利用或

①《中华人民共和国民法典》第二百二十九条至第二百三十二条规定的登记即为宣示登记。其中第二百三十条规定，因继承取得物权的，自继承开始时发生效力。第二百三十二条规定，处分依照本节规定享有的不动产物权，依照法律规定需要办理登记的，未经登记，不发生物权效力。

②张明楷：《论盗窃财产性利益》，载《中外法学》2016年第6期。

者处分。①司法实践对成立盗窃罪的占有一般适用“控制+失控”标准。将他人 的不动产产权转移到自己名下，行为人已经在法律上对不动产产权形成了新的 占有，并基于该占有可以实施对不动产的处分行为。同时，排除了原权利人对 不动产产权法律上的占有，即便原权利人仍可能在物理上占有、使用不动产， 但原权利人已不能无妨碍地处分不动产产权，该不动产也已面临被擅自增加负担、处置的现实、紧迫风险。原权利人能否通过自力救济恢复不动产产权，不 影响行为人盗窃罪的成立。

从法律规定来看，该行为被评价为盗窃罪不存在法律障碍。刑法将盗窃罪的罪状表述为“盗窃公私财物”，且没有相应的限制性或排除性规定，认为《中华人民共和国刑法》规定的财物包括不动产，不违反罪刑法定原则。

从社会观念来看，社会观念对不动产作为盗窃对象的理解障碍主要在于不动产不可移动的物理属性，但不动产产权的财产性利益可被他人占有的观念， 不超出一般社会观念。

从立法目的来看，从有利于保护公私财产所有权出发，不宜对财物作限制 解释，②否则可能导致立法间隙，无法实现对公民财产权利，而且是重大财产 权利的保障。

关于盗窃的数额， 一般为过户时房产的价值。 一些情况下，行为人只实际 部分处分了不动产产权的财产性利益，如处分了房产的部分担保份额，但在不动产产权被其占有的情况下，其已具备处置不动产全部财产性利益的可能，实际处置结果只

取决于其主观意志。还需注意的是，如行为人通过伪造继承等手段过户的房产是已经被设置抵押权的房产，房产可供处置的财产性利益客观受限，此时，房产过户时尚可处分的财产性利益就是行为人的犯罪数额。

综上，窦某某擅自将其母名下的房产转移给自己占有的行为，可以认定为盗窃罪，盗窃数额为过户时房产的市场价值。

①杨兴培：《龚某盗卖其父房产一案之我见——兼谈不动产可以成为盗窃罪之对象》，载《政治与法律》2012年第3期。

②高铭暄、马克昌：《刑法学》，北京大学出版社、高等教育出版社2017年版，第556页。

3. 对家庭成员或近亲属间盗窃犯罪从宽处理的政策把握。司法解释对家庭成员或近亲属间盗窃犯罪从宽处理作出规定。①在适用这一规定时要注意把握：一是因盗窃行为产生的家庭内部的矛盾对立已化解，只有这样维护和促进家庭和亲属关系和谐、稳定的政策目的才能实现；二是法律未对数额作出限制性规定，即便是犯罪数额巨大或特别巨大，如获得家庭成员或者近亲属谅解，亲属关系已修复，社会危害性不大时，也可不认为是犯罪；三是最终是否追究刑事责任应当综合判断，司法解释的规定并不是家庭成员或近亲属间盗窃行为的定罪条款，对于犯罪动机、手段、情节恶劣，主观恶性强，人身危害性大，社会影响恶劣的被告人，即便是家庭成员或近亲属已谅解，也应追究其刑事责任。

本案中，窦某某实施前述行为既没有采用危险性、破坏性手段，也没有用于赌博、吸毒、挥霍浪费等，手段、情节并不十分恶劣；其间，其母亲始终占有和使用房产，之后经过行政诉讼，房屋所有权转移登记已被撤销，除对倪某设置的抵押权外，窦母其他不动产产权已恢复，没有实际造成巨额财产损失；母亲已谅解窦某某，审判阶段表示愿意替窦某某的其他犯罪退赔；公诉机关就该节亦未予指控窦某某；故可不追究窦某某盗窃行为的刑事责任。

二、窦某某将通过盗窃等违法方式取得的房产用于抵押借款的行为成立合同诈骗罪

1. 窦某某客观上实施了欺骗行为。欺骗的核心在于让被害人陷入错误认识进而交付财物。为了欺骗而虚构或隐瞒的

事实，通常是对权利人决策起基础性、关键性作用的事实，即这一事实如果存在瑕疵或争议，从一般社会观念来看，权利人极可能作出相反的处置决策。在担保中，债权人之所以要求设立担保，就是为了保障债权的实现，如果担保物存在争议或瑕疵，其债权就具备失去保障的现实风险，一般理性的债权人如果知道真相，极有可能拒绝借款。因而担保物不存在争议或瑕疵，就是这一关系中的基础性、关键性事实。有意见认为，

①《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，偷拿家庭成员或者近亲属的财物，获得谅解的，一般可不认为是犯罪；追究刑事责任的，应当酌情从宽。

二、破坏社会主义市场经济秩序罪

窦某某以其在法律上有产权的房产抵押借款，倪某作为善意第三人可以主张权利，倪某的债权仍具有保障。这是一种可能的事后救济，并不能据此否认窦某某行为的欺骗性，因为即便是存在这一救济途径，也可能实质上影响到债权人的出借决定，通常理性、善良的债权人不是以实现担保权为目的来出借债权的，何况是有瑕疵或争议的担保。从现实经验来看，担保权实现的过程也通常周折而不确定。还有意见认为，窦某某对于倪某是隐瞒了真相，但其不具有披露真相的义务，笔者认为，诚实信用原则正是窦某某披露真相义务的来源。

2. 窦某某主观上具有非法占有的目的。关于如何判断行为人的非法占有目的，诸多规范性文件已作出指引，可作为综合判断的参考。结合到本案，窦某某不具备还款能力，其盗窃其母房产用于抵押借款的原因正是其无资金来源，且仅凭自身已无法实现借款；借款后未将钱款用于约定用途；当其还款不能时，其一方面让其母通过诉讼收回房产，另一方面自行逃匿，致使倪某债权无法实现；应认为窦某某具有非法占有目的。

3. 处分赃物的行为要成立不可罚的事后行为必须以不侵犯新的法益为前提。刑法理论认为，不可罚的事后行为不成立其他犯罪是因为事后行为没有侵犯新的法益，缺乏期待可能性。^①虽然学界对不可罚的事后行为是否能扩大、加深对原法益的侵害存在争鸣，但对该行为不能侵犯新的法益已经形成共识。^②而同一法益至少包括法益主体的同一性，如果事后行为侵害了原被害人之外的第三人的利益，当然不属于同一法益。本案中，窦某某盗窃不动产时侵害的是其母亲的财产权益；用盗窃的不动产设立担保时，向倪某隐瞒了其实际上无权处分

房产的真相，最终导致了倪某的损失，是对新法益的侵害，同时也不缺乏 期待可能性，不属于不可罚的事后行为。

三 、对窦某某实施的数个犯罪行为应该从一重处罚

牵连犯是指行为人虽实施了多个犯罪行为并触犯多个罪名，但出于一个犯罪目的，行为间具有手段和目的、原因和结果等牵连关系。传统刑法理论对牵

①张明楷：《刑法学》，法律出版社2007年版，第368~369页。

②贾学胜：《事后不可罚行为研究》，载《现代法学》2011年第5期。

连犯处断采用的吸收原则，即按照全部行为中触犯的罪名中最重的罪论处。判断牵连犯除要坚持主客观相统一原则，即主观上是为了实现一个结果，客观上行为间存在内在因果关系外，还要避免同一危害行为同时被作为不同犯罪的构成要件而重复评价。还需要注意的是，牵连犯的多个行为是实质的数罪，处断的一罪，因而在重罪不构成或不视为犯罪时，还应对作为手段或原因的轻罪行为进行刑法评价。

本案中，窦某某盗窃不动产产权的目的就是对不动产设立抵押以便于骗取借款。窦某某盗窃行为使得其具有了外观合法的不动产产权，这是其能使倪某陷入错误认识交付财物的手段和原因。窦某某实施合同诈骗时，隐瞒的真相是其伪造母亲已去世擅自过户房产给自己占有的事实，该事实既是合同诈骗罪隐瞒真相的构成要件，又已经被盗窃罪所评价。综上，窦某某的盗窃罪和合同诈骗罪系牵连犯。

编写人：北京市第三中级人民法院 刘泽
杨隽男

传销资金是上架费还是其他费用

—— 李某甲等组织、领导传销活动案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市平谷区人民法院(2023)京0117刑初83号刑事判决书

2. 案由：组织、领导传销活动罪

【基本案情】

2022年4月，被告人李某甲成立某科技公司，其为该公司实际控制人，并

以该公司名义在网络上开设某玉石交易平台，被告人李某乙在某玉石交易平台中承担管理、宣传等职责，二人以网上买卖玉石为名，引诱他人购买成本与售价严重背离的玉石成为平台会员，再以发展会员的人数为依据进行返利，诱使会员继续发展他人参加，通过收取玉石交易上架费的方式获取巨额经济利益。被告人王某某作为被告人李某甲和李某乙的下线，于2022年5月成立某公司，从某玉石交易平台分立，以该公司名义在网络上开设某1玉石交易平台，运作模式与博某某交易平台相同。被告人李某甲、李某乙所经营管理的某玉石交易平台陆续分立出锦某某等多个下线平台，并向下线平台所属的某1公司等多个公司收取技术服务费与上架费提成。被告人李某甲、李某乙、王某某是其各自玉石交易平台的组织者、领导者，所经营的平台内部参与传销活动的人员均超过30人，且层级均在3级以上。经鉴定，某科技公司收取上架费共计人民币7370931元，某公司收取上架费共计人民币1298140.01元，某1公司收取上架费共计人民币7006268.02元。某科技公司通过技术服务费的形式收取3家公司共计人民币433202元，被告人李某甲通过其个人账户收取某1公司上架费提成共计人民币771745元，被告人李某乙通过其个人账户收取某1公司上架费提成共计人民币400000元。被告人李某甲个人账户共计流入涉案款项人民币1495893元，被告人李某乙个人账户共计流入涉案款项人民币929439元，被告人王某某个人账户共计流入涉案款项人民币512892.85元。

【案件焦点】

本案传销资金是上架费还是其他费用。

【法院裁判要旨】

北京市平谷区人民法院经审理认为：被告人李某甲、李某乙、王某某以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，再以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，应分别依法予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告

人李某甲、李某乙、王某某犯有组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人李某甲、李某乙、王某某具有自首情节，均自愿认罪认罚，且被告人李某乙、王某某在共同犯罪中系从犯，故可对被告人李某甲依法从轻处罚，对被告人李某乙、王某某依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：

一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；

二、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；

三、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；

四、在案扣押的物品，均由公安机关依法处理。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案是收取上架费类型的传销案件。本案中，对于什么是传销资金存在不同意见。有意见认为，应当认定为上架费，还有意见认为，应认定为交易资金。判决最后采纳认定为上架费的意见。

一、传销资金数额是认定加重情节的依据

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条的规定，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者应予立案追诉。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)第一条重申了上述追诉标

276 中国法院2025年度案例·刑事案例二

准的规定。第四条 第二项同时规定了组织、领导的传销活动罪加重情节即“情节严重”的认定

标准，即(1)组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上；(2)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上；(3)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达60人以上；(4)造成参与传销活动人员精神失常等严重后果；(5)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。根据上述规定，传销资金数额不是组织、领导传销活动罪的定罪依据，而是本罪加重情节即“情节严重”的认定依据之一。当传销组织的组织者、领导者的行为已达到组织、领导传销活动罪的追诉标准，但不具有其他四种情形时，传销资金数额就成为判断组织、领导传销活动罪是否达到情节严重的关键事实，如何界定传销资金，就成为司法人员面临的直接关系到正确认定“情节严重”和合理量刑的重要问题。

二、传销资金是上架费，不是交易金额

传销资金是指什么资金，目前尚无立法、司法解释及司法解释性文件予以明确。组织、领导传销活动刑事案件中，组织、领导者可能以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，也可能以参加者的业绩或者参加者发展一定层级以下的下线的业绩作为计算回报的依据，还可能以两者结合等方法计算回报。传销活动中可能出现会员费、入门费、业绩、交易资金、上架费、提成、分红等数额。在收取上架费的传销案件中，只有上架费能被认定为传销资金。主要理由如下：

1. 将上架费认定为传销资金更能实现罪刑相适应。刑法规定的组织、领导传销活动罪的传销行为与《禁止传销条例》规定的传销行为略有不同。根据《禁止传销条例》第二条、第七条的规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。包括三种传销类型，即“拉人头”式传销、收取“入门费”式传销及“团队计酬”式传销。而《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪的传销行为仅包括前两

种类型，不包括最后一种类型，即以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的“团队计酬”式传销。由此可见组织、领导传销活动罪的社会危害性主要是骗取财物和扰乱经济社会秩序。交易资金一般绝大部分不交纳给传销平台，而上架费是下线参加传销活动人员交纳给传销平台的资金，是处于金字塔顶端的组织者、领导者实际骗取的钱款，最能体现组织、领导传销活动罪的社会危害性，故将上架费认定为传销资金，最能实现罪刑相适应。

2. 将上架费认定为传销资金更符合《意见》的原意。《意见》主要考虑组织、领导传销活动罪行为人主要目的是骗取财物，其涉案资金数额大小是判断其社会危害性的重要标准之一，实践中参与传销活动人员缴纳的“入门费”资金数额相差悬殊，为与第一项数量标准——组织、领导的参与传销活动人员累计120人以上——保持大致平衡和社会危害性相当，故作出第四条第二项的规定。只有所有人缴纳的“入门费”资金数额标准相同，并大体为每人2万元时，才能计算出与第一项数量标准保持大致平衡和社会危害性相当的250万元。上架费最可能符合这个条件，同一传销组织的各参与人交易资金数额则可能存在较大差异。

3. 将上架费认定为传销资金更符合《意见》的字面含义。《意见》中的传销资金前面有修饰语“缴纳的”，这意味着只有缴纳给组织者、领导者的资金才是传销资金。上架费正是这种资金，而交易资金一般不交纳或不全部交纳给组织者、领导者或传销平台。

三、构成加重情节应当符合定罪要求的参与人数和层级

《意见》第四条规定，认定为情节严重的，应当是符合本意见第一条一款规定的传销组织的组织者、领导者。对这一规定，应当理解为构成组织、领导传销活动罪加重情节即情节严重，应当以行为人符合定罪要求为前提，即涉案行为应当达到定罪要求的组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级有3级以上。第四条规定的五种情形，都应当同时达到这一要求。如果达不到这一要求，涉案行为就不构成组织、领导传销活动罪，本罪的基本构成与加重构成是递进关系，如果涉案行为不构成本罪，就更不能构成情节严重。实践中不排除

出现涉案行为符合第4条规定的五种情形之一，如传销资金数额累计250万元以上，但未达到人数在30人以上且层级在3级以上的标准。这种情况就不能以本罪定罪，更不能认定本罪情节严重。

本案中，审判机关查明了参与传销活动的人数、层级、涉案公司收取的上架费、流入个人账户涉案款，这里的涉案款包含部分交易资金。根据以上分析，只有上架费最适合认定为传销资金。故，一审判决认定上架费为传销资金进而认定本案情节严重的处理是正确的。

编写人：北京市第二中级人民法院 杨子良

北京市平谷区人民法院 孙国立

网络虚拟币传销犯罪的认定

—— 徐某某等组织、领导传销活动案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通经济技术开发区人民法院(2023)苏0691刑初63号刑事判决书

2. 案由：组织、领导传销活动罪

【基本案情】

2020年6月至7月，被告人徐某某伙同黄某、杨某、陈某等人策划并发起了名为“某世界”的项目。该项目通过会员推荐注册制度，在国内外广泛招募会员。平台会员以某币充值兑换平台内发行的E虚拟币，使用E币购买“充能舱”，方可获得E币收益。项目在无任何实际经营活动的情况下，以区块链技

术应用和虚拟币升值前景为幌子，诱骗会员投资获取静态收益，并通过拉人头发展下线投资获取动态收益。

2020年12月14日，因内部矛盾，徐某某退出项目并提走平台内会员充值的部分某币，折合人民币约276万元。经鉴定，截至2020年12月14日0时，该平台共有会员账号43006个，1302层级，其中购买“充能舱”的会员账号2038个，23层级，会员充值E币419万余个，折合某币约184万个，折合人民币1203余万元。

徐某某离开后，黄某、杨某、陈某继续运营“某世界”平台，并将原公司注销后成立了新的科技公司。经鉴定，截至2022年11月7日0时，该平台共有会员账号73207个，1302层级，其中购买“充能舱”的会员账号11055个，64层级，会员充值E币4175余万个，折合某币1833余万个，折合人民币约1.15亿元。

【案件焦点】

被告人的行为如何定性。

【法院裁判要旨】

江苏省南通经济技术开发区人民法院经审理认为：被告人徐某某、黄某、杨某、陈某组织、领导以投资为名，要求参加者投资获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，徐某某、黄某、杨某、陈某在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。徐某某、黄某、杨某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人徐某某对整个传销平台的开发、运营发挥着关键作用，其退出传销组织后的犯罪不计入被告人徐某某的犯罪数额，在其犯罪事实的基础上，可以酌情从轻处罚。部分被告人退出部分违法所得并预缴罚金，对上述被告人均可以酌情从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。

江苏省南通经济技术开发区人民法院依照，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第四条，作出如下判决：

一、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元；

二、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币55万元；

三、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元；

四、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币50万元；

五、继续追缴被告人徐某某违法所得，予以没收，上缴国库；

六、被告人杨某、陈某已退出的违法所得，均予以没收，上缴国库；

七、继续追缴被告人黄某违法所得及收益，对其使用部分违法所得购买的房产予以没收，上缴国库；

八、公安机关已扣押“某世界”平台涉案资金等，均由扣押机关予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

与传统传销相比，网络型传销更具新颖性、隐蔽性、欺骗性和迷惑性，对经济和社会秩序破坏严重。在本案中，徐某某等通过虚拟货币平台组织、领导传销活动，范围广、人数多、层级杂、金额大，扰乱金融市场秩序，认定为组织、领导传销活动罪有充分依据。

一、网络型组织、领导传销活动罪客观特征认定

虽网络型与传统型在组织和运行方式上有别，但本质不变。
认定需遵循相

